

1500092-81.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500092-81.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2011270/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 22418154 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

120/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2011270 - 02º D.P. PIRACICABA, 120/22/922

- 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE SOARES DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 22 dias do mês de junho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a). Daniela Bataíha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) HENRIQUE SOARES DA SILVA e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Vítor Souza Lopes e Luan Moreira da Silva.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s)

acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Vitor e Luan) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza,

HENRIQUE SOARES DA SILVA está sendo processado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia no dia 12 de janeiro de 2022, por volta de 21h20m, na rua Porto Rico, altura do numeral 263, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, trazia consigo 08 porções de cocaína e guardava e/ou mantinha em depósito 130 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 09/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 109/111).

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

Segundo se apurou, policiais militares passavam pela "área verde" existente no local, conhecido "ponto de comércio de drogas", quando avistaram e suspeitaram do denunciado, que estava abaixado de costas na via pública e ao perceber a aproximação da viatura, assustou-se e levantou-se rapidamente.

Feita abordagem de praxe, em poder do réu foram localizadas oito porções de cocaína. No local em que ele havia sido visto abaixado foram encontradas 130 porções de cocaína, idênticas àquelas apreendidas em seu poder, divididas em "mucas".

Instado, informalmente, o denunciado alegou que "estava ali para fazer um dinheiro e que havia recebido a droga de um indivíduo conhecido como Atilio".

O denunciado foi apresentado à autoridade policial e estava alterado, aparentemente sob efeito de entorpecentes. Indagado, alegou que estava "guardando nove pinos de cocaína, que havia acabado de comprar e que iria usar depois".

No entanto, diante das circunstâncias apuradas, apreensão de significativa quantidade de porções individualizadas, além da confissão informal e reincidência específica, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Com efeito, o policial militar Vitor Souza Lopes narrou "no dia de hoje por volta das 21:20 horas, estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Água Branca, quando a equipe policial adentrou a Rua Porto Rico, altura do numeral 263, sendo este local um área verde, local já conhecido por intenso comercio de drogas, quando foi visualizado pelos policiais um indivíduo que estava abaixado na via pública, de costas, sendo que com aproximação da viatura policial, este individuo se levantou rapidamente e se assustou com a presença dos policiais. Os policiais diante do fato, abordaram este individuo, que em revista pessoal foi localizado em seu bolso a quantia de 8 micro tubos, transparentes, de substancia aparentando ser COCAINA. Este indivíduo se identificou aos policiais como sendo HENRIQUE SOARES DASILVA, que em entrevista informal com os policiais alegou que estava no local para fazer um dinheiro, ademais manteve-se em silencio. Esclarece o policial que no local onde HENRIQUE estava abaixado, no pé de uma arvore, escondido em um moita de mato, foi localizado uma sacola, com 6 "mucas", contendo cada uma 20 micro pinos, e 1 "muca" com 10 micro pinos, somando a quantia de 130 micro pinos de substancia aparentando ser COCAINA, semelhantes as que foram localizadas na posse de HENRIQUE, totalizando aquantia de 138 micro pinos de COCAINA. Questionado novamente pelos policiais

HENRIQUE alegou que quem lhe fornecia as drogas era um tal de "Atilho", que desconhece e que estava no local apenas para fazer um dinheiro. Esclarece o policial que HENRIQUE, estava agitado e inquieto, aparentemente sob o efeito de drogas. Por fim, alega o policial que não houve a necessidade de usar algemas" (fls. 04/05).

Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial. Desconhece a pessoa Atilio. Não a conhece. Não foi abordada com o réu.

No mesmo sentido o policial militar Luan Moreira da Silva que asseverou "no dia de hoje por volta das 21:20 horas, estavam e patrulhamento de rotina pelo Bairro Agua Branca, quando a equipe policial adentrou a Rua Porto Rico, altura do numeral 263, sendo este local um área verde, local já conhecido por intenso comercio de drogas, quando foi visualizado pelos policiais um indivíduo que estava abaixado na via pública, de costas, sendo que com aproximação da viatura policial, este individuo se levantou rapidamente e se assustou com a presença dos policiais. Os policiais diante do fato, abordaram este individuo, que em revista pessoal foi localizado em seu bolso a quantia de 8 micro tubos, transparentes, de substância aparentando ser COCAINA. Este indivíduo se identificou aos policiais como sendo HENRIQUE SOARES DA SILVA, que em entrevista informal com os policiais alegou que estava no local para fazer um dinheiro, ademais manteve-se em silencio. Esclarece o policial que no local onde HENRIQUE estava abaixado, no pé de uma arvore, escondido em um moita de mato, foi localizado uma sacola, com 6 "mucas", contendo cada uma 20 micro pinos, e 1 "muca" com 10 micro pinos, somando a quantia de 130 micro pinos de substancia aparentando ser COCAINA, semelhantes as que foram localizadas na posse de HENRIQUE, totalizando a quantia de 138 micro pinos de COCAINA. Questionado novamente pelos policiais HENRIQUE alegou que quem lhe fornecia as drogas era um tal de "Atilho", que desconhece e que estava no local apenas para fazer um dinheiro. Esclarece o policial que HENRIQUE, estava agitado e inquieto, aparentemente sob o efeito de drogas. Por fim, alega o policial que não houve a necessidade de usar algemas. Assim, tendo em vista a grande quantidade de drogas que foi apreendida em seu poder, aparentando ser do tráfico, o policial deu voz de prisão em flagrante, declarando seus direitos constitucionais o encaminhou a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária" (fls. 06).

Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial. Não apreenderam dinheiro. Não conhecia o réu. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. O réu disse que precisava de dinheiro, motivo pelo qual estava vendendo. Foi o réu que mencionou um tal de Atilio, mas não havia mais ninguém no local. Não tiveram contato com esta pessoa.

Perante a autoridade policial, o réu alegou "estava guardando 9 pinos para cheirar. Alega que tinha acabado de comprar as drogas. Alega que usou muita droga hoje. Alega que é usuário contumaz. Ademais manteve-se em silencio".(fls. 07/08).

Interrogado em juízo, o réu alegou que o adolescente Atilio estava lá e os policiais determinaram a ele que o acusasse de possuir a droga, pois "ele é menor". Já teve passagem e o local é de tráfico de drogas. Não estava mexendo nas drogas. Os policiais não apreenderam nada consigo, nem dinheiro. A droga apreendida não foi citada pelos policiais. Os policiais apreenderam a droga há cem metros de onde estava, ou seja, com Atilio. A droga não lhe pertencia. Instado sobre o que falou na delegacia, retratou-se e disse que "estava com 9 pinos para o seu consumo". Comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência da ação. A narrativa dos policiais foi firme e uníssona em confirmar que passavam pelo local, conhecido pelo tráfico ilícito de drogas, quando avistaram e suspeitaram do réu que estava abaixado, mexendo em algo. Ao vê-los, o réu levantou-se rapidamente. Feita abordagem, em poder do réu foram localizadas 8 porções de cocaína. No local em que ele mexia foram apreendidas 130 porções idênticas àquelas que estavam em seu poder. Informalmente, ele confessou o crime.

Assim, não há dúvidas que o entorpecente descrito na inicial estava na posse do réu e destinava-se ao crime imputado na inicial.

Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos policiais militares, devendo ser valorados como as demais provas do processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso

Induvidoso, portanto, que a droga destinava-se à mercancia ilícita. O fato do réu alegar ser usuário em nada altera o quadro apurado. Portanto, imperiosa a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de drogas. Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira-fase a pena deve ser fixada acima do mínimo legal diante da considerável quantidade de porções apreendidas e respectiva natureza, conforme dispõe o artigo 42, da Lei de Drogas.

A reincidência do réu fará com que a pena seja exasperada em 1/6. Ausentes circunstâncias atenuantes e causas de aumento.

A quantidade de entorpecente apreendida demonstra que ele se dedicava ao crime imputado. Além disso, o réu é reincidente específico, razão pela qual deve ser afastada a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Tratando-se de delito assemelhado ao hediondo e tendo-se em conta a necessidade de se individualizar a pena para a adequada prevenção e reprovação, incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o réu iniciar o desconto da pena no regime fechado.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente garantia da ordem pública, deverá ser indeferido apelo em liberdade.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Henrique Soares da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 85-87), no dia 12 de janeiro de 2022, por volta de 21h20, na rua Porto Rico, altura do numeral 263, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Henrique trazia consigo 08 porções de cocaína e guardava e/ou mantinha em depósito 130 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Ainda de acordo com a inicial, policiais militares passavam pela "área verde" existente no local, conhecido "ponto de comércio de drogas", quando avistaram e suspeitaram do réu, que estava abaixado de costas na via pública e ao perceber a aproximação da viatura, assustou-se e levantou-se rapidamente. Feita abordagem de praxe, em poder do réu foram localizadas oito porções de cocaína. No local em que ele havia sido visto abaixado foram encontradas 130 porções de cocaína, idênticas àquelas apreendidas em seu poder, divididas em "mucas". Instado, informalmente, o réu alegou que "estava ali para fazer um dinheiro e que havia recebido a droga de um indivíduo conhecido como 'Atilio'". O réu foi apresentado à autoridade policial e estava alterado, aparentemente sob efeito de entorpecentes.

Interrogado em solo policial, o réu disse que "estava guardando 9 pinos para cheirar. Tinha acabado de comprar as drogas. Usou muita droga hoje. É usuário contumaz" (fls. 7-8).

Vitor Souza Lopes, policial militar, contou que: "no dia de hoje por volta das 21:20 horas, estavam e patrulhamento de rotina pelo bairro Água Branca, quando a equipe policial adentrou a rua Porto Rico, altura do numeral 263, sendo este local um área verde, local já conhecido por intenso comercio de drogas, quando foi visualizado pelos policiais um indivíduo que estava abaixado na via pública, de costas, sendo que com aproximação da viatura policial, este indivíduo se levantou rapidamente e se assustou com a presença dos policiais. Os policiais diante do fato, abordaram este indivíduo. Em revista pessoal foi localizado em seu bolso a

quantia de 8 micro tubos, transparentes, de substância aparentando ser cocaína. Este indivíduo se identificou aos policiais como sendo Henrique Soares da Silva. Em entrevista informal com os policiais alegou que estava no local para fazer um dinheiro, ademais manteve-se em silêncio. No local onde Henrique estava abaixado, no pé de uma árvore, escondido em uma moita de mato, foi localizado uma sacola, com 6 'mucas', contendo cada uma 20 micro pinos, e 1 'muca' com 10 micro pinos, somando a quantia de 130 micro pinos de substância aparentando ser cocaína, semelhantes as que foram localizadas na posse de Henrique, totalizando aquantia de 138 micro pinos de cocaína. Questionado novamente pelos policiais, Henrique alegou que quem lhe fornecia as drogas era um tal de 'Atilho', que desconhece e que estava no local apenas para fazer um dinheiro. Henrique, estava agitado e inquieto, aparentemente sob o efeito de drogas. Por fim, não houve a necessidade de usar algemas. Assim, tendo em vista a grande quantidade de drogas que foi apreendida em seu poder, aparentando ser do tráfico, deu voz de prisão em flagrante, declarando seus direitos constitucionais e o encaminhou a esta Delegacia de Polícia" (fls. 4). No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Luan Moreira da Silva (fls. 6).

Às fls. 15-16, auto de exibição e apreensão. Às fls. 18-20, laudo de constatação.

Às fls. 32, fotografia. Às fls. 109-111, laudo de exame definitivo.

Às fls. 45-47, juntada certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 0005872-81.2019.8.26.0502 - tráfico de drogas - trânsito em julgado para a Defesa em 25/10/2019).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

Com relação à materialidade e autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvido, inicialmente, o policial militar Luan Moreira da Silva. Informou que estava em patrulhamento de rotina pelo bairro da Água Branca, bastante conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Ao entrar na rua dos fatos, viram um indivíduo abaixo, de costas para a equipe, mexendo em algo em uma área verde, ao pé de uma árvore. Ao ver a equipe, levantou-se e assustou-se. Abordado, em revista pessoal, com o réu, localizaram 8 pinos de cocaína. No local em que viram o réu abaixado, localizaram mais 130 porções de cocaína embaladas da mesma forma. Não tinha dinheiro. Não conhecia o réu. Somente sabia que o local era conhecido pela venda de drogas. Perguntado sobre a localização da pessoa de nome Atilio, disse que não teve contato, seria o réu que mencionou essa pessoa durante a abordagem. O réu estava nervoso e dizia a todo tempo que precisava de dinheiro. Quando o réu foi preso não havia outras pessoas no local.

b) Na sequência, foi ouvido policial militar Vitor Souza Lopes. Estava em patrulhamento pelo bairro e, ao entrar em determinada rua, viram uma pessoa de costas, abaixada perto de uma árvore. O motorista acelerou o carro e realizaram a abordagem. Em busca pessoal no réu localizaram 8 porções de cocaína e, ao realizar buscas nas imediações. Próximo ao local em que ele estava abaixado antes da abordagem havia 6 "mucas" com cocaína. Indagado, o sujeito disse que estava no local para "fazer um dinheiro". [Havia outras pessoas perto dele, na região? Ele estava conversando com alguém?] No momento em que ingressaram na via, ele não tinha visão da viatura, e ele estava sozinho do lado direito da viatura. Ele não estava conversando com ninguém. Não conhecia o réu. Não tinha dinheiro com ele. Estava nervoso e agitado, parecia que tinha acabado de usar drogas. [Ele chegou a falar de outra pessoa?] Não se recorda de o preso ter falado de alguém. [Qual a participação da pessoa de nome Atilio na ocorrência?] O réu mencionou como sendo a pessoa para quem ele vendia a droga. Na ocorrência, ninguém mais foi abordado.

c) Por fim, foi interrogado o réu Henrique Soares da Silva. Estava agachado, assustou-se porque já tinha ingerido tanto droga quanto álcool. Atilio estava próximo dele e também foi preso. Os policiais levaram Atilio para próximo do réu e depois os separaram. Disseram para Atilio que deveria dizer que a droga era do réu porque Atilio é adolescente e não ficaria preso. As drogas não eram dele, eram de Atilio. Estava mesmo abaixado, alucinando por ter usado droga, mas as drogas não são suas. Atilio estava saindo de um terreno e as drogas encontradas estavam nesse terreno, não onde estava abaixado. O réu tinha com ele 9 pinos de cocaína, que

tinha comprado. O restante de droga não é sua. Nem na delegacia foi informado que lhe imputavam toda a droga dos autos, somente soube no dia 21 de março, quando foi citado, que a acusação envolvia esse montante de drogas. Relatou que é HIV positivo e está recebendo os medicamentos no sistema prisional.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

De rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações deles são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decreta sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, caso se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga e a quantidade de entorpecente apreendida na posse do réu é compatível com o uso de drogas - 8 porções de cocaína.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminente Relatora, "No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista das Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a médica de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade

intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS

(Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RJ), constata que cada pedra de crack pode variar de 0,1 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos", de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína." (p. 8-9 do Acórdão)".

Outrossim, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: "A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder dos acusados se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo" (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, e mostra-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas e exsurtem algumas consequências.

a) Da absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição em razão da inconstitucionalidade do referido tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o qual fere o disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: "Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]" (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344).

Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve,

a propósito, Nilo Batista: "O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais" (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas.

Diante da alegação ora invocada, de rigor seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, com consequente afastamento da imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas e absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Da aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas
Rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Da pena-base

Na remota hipótese de condenação pela prática de tráfico de drogas, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso e a quantidade de drogas não é exacerbada, não justificando uma reprovação penal maior.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a reincidência deve ser compensada com a confissão, ainda que apenas a informal, sendo ambas as circunstâncias preponderantes (art. 67. CP).

No mais, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma

vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). O réu está respondendo ao processo em liberdade, compareceu aos atos processuais e não indica que se furtará ao processo.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

HENRIQUE SOARES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta de 21h20, na Rua Porto Rico, altura do numeral 263, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, trazia consigo 08 porções de cocaína e guardava e/ou mantinha em depósito 130 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares passavam pela "área verde" existente no local, conhecido "ponto de comércio de drogas", quando avistaram e suspeitaram do réu, que estava abaixado de costas na via pública e ao perceber a aproximação da viatura, assustou-se e levantou-se rapidamente.

Feita abordagem de praxe, em poder do réu foram localizadas oito porções de cocaína. No local em que ele havia sido visto abaixado foram encontradas 130 porções de cocaína, idênticas àquelas apreendidas em seu poder, divididas em "mucas".

Instado, informalmente, o réu alegou que "estava ali para fazer um dinheiro e que havia recebido a droga de um indivíduo conhecido como "Atilio"".

O réu foi apresentado à autoridade policial e estava alterado, aparentemente sob o efeito de entorpecentes. Indagado, ele alegou que estava "guardando nove pinos de cocaína, que havia acabado de comprar e que iria usar depois".

No entanto, diante das circunstâncias apuradas, apreensão de significativa quantidade de porções individualizadas, além da confissão informal do réu e reincidência específica, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida (fls. 88/89), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 90/91).

Notificado (fls. 96), o réu apresentou defesa prévia, na qual pleiteou a rejeição da denúncia por falta de justa causa (fls. 100).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência (fls. 113/116). O réu foi citado (fls. 133).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, no laudo de constatação de fls. 18/20, na fotografia de fls. 32, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 109/111, segundo o qual foi detectada cocaína nos materiais apreendidos.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu disse que estava guardando 09 pinos para cheirar.

Tinha acabado de comprar as drogas. Usou muita droga na data dos fatos. É usuário contumaz. (fls. 07/08).

Em Juízo, o réu afirmou que os fatos são verdadeiros. O que ocorreu foi o que os policiais falaram. Estava agachado e, quando viu os policiais, assustou-se, porque tinha consumido drogas. Levantou-se, quando viu os policiais. Atilio estava nas proximidades. Os policiais levaram Atilio para perto dele e, depois, ele foi levado para longe. Os policiais disseram que Atilio teria que dizer que a droga era dele.

Estava sob efeito de drogas e de álcool. Estava agachado, na alucinação da droga, não mexia no entorpecente. Não ele, não havia dinheiro ou droga. A droga apreendida estava com Atílio. Atílio estava saindo do terreno e também foi abordado. A droga apreendida estava nesse terreno. Tinha pegado 09 pinos de cocaína. Na verdade, tinha 09 pinos de cocaína, consigo, quando foi abordado. Somente soube do restante da droga 02 meses depois, porque nem na Delegacia sabia que tinha essa quantidade de drogas. Faz uso de cocaína, mas conseguia ficar sem consumi-la. Tem doença crônica de HIV, mas a cadeia não faz o tratamento correto. Está recebendo os remédios.

A autoria foi comprovada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

O policial militar Vitor Souza Lopes narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro, quando adentraram a rua e avistaram uma pessoa de costas, abaixada, mexendo em algo próximo de uma árvore. De imediato, realizaram a abordagem. Em busca pessoal, localizaram 08 microtubos de cocaína e realizaram buscas nas imediações. Próximo ao local onde ele estava agachado, encontraram uma sacola contendo drogas. Havia 06 "mucas" com 20 microtubos e um saco menor com 10 microtubos. Indagado, o réu disse que estava no local para fazer dinheiro. Quando ingressaram na via, o réu estava sozinho, do lado direito da viatura. Não conhecia o réu. O réu não tinha dinheiro consigo. Ele estava nervoso e agitado, parecia que tinha acabado de utilizar droga. Não se recorda que o réu tivesse falado de alguém. Desconhece a pessoa de nome Atílio. O réu falou que vendia para uma pessoa de nome Atílio. Não abordaram ninguém com esse nome.

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Luan Moreira da Silva, que relatou que estavam em patrulhamento, pelo bairro Água branca, em perímetro bem conhecido por pontos de venda de drogas. Ao adentrarem a rua Porto rico, avistaram o réu agachado, de costas para a equipe, mexendo em alguma coisa, no pé de uma árvore. Quando ele viu a equipe, logo se levantou, se assustou e foi abordado. Em revista pessoal, com o réu, encontraram 08 microtubos de cocaína. Conversaram com o réu e seu parceiro fez a busca no perímetro e, no local onde o réu mexia, encontraram uma sacola com 138 porções de cocaína. Em conversa, o réu alegava que precisava de dinheiro e, por isso, estava na venda de drogas. As drogas encontradas no pé da árvore e na posse do réu eram idênticas. Não encontraram dinheiro com o réu. Não conhecia o réu. Henrique a todo momento estava nervoso e disse que estava na venda. O réu falou que vendia para Atílio. Não havia mais pessoas paradas no local. Quando ingressaram na rua, só viram o réu. Não sabe quem é Atílio e não teve contato com ele.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Em solo policial, o réu alegou ser usuário de drogas e ter adquirido 09 porções de cocaína para cheirar. Judicialmente, o réu alegou que estava só com 09 pinos de cocaína na sua posse, dizendo não ter conhecimento sobre o restante da droga, que era de Atílio.

Os policiais militares narraram que estavam em patrulhamento por local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas intenso, quando avistaram o réu agachado na via pública, de costas para a viatura. Quando se levantou, o réu se assustou com a aproximação da viatura e foi abordado. Em sua posse, os policiais encontraram 08 microtubos de cocaína. No local onde o réu mexia, antes da abordagem, ou seja, no pé de uma árvore, no meio de uma moita, os policiais encontraram uma sacola, contendo 04 mucas, com 20 microtubos de cocaína cada uma, e 01 muca com 10 porções de cocaína, somando 130 porções. Todas as drogas estavam embaladas de forma idêntica. Questionado, inicialmente o réu disse que estava fazendo um dinheiro e que trabalhava para Atílio, pessoa que não foi abordada pelos policiais. Nesse sentido temos duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, no sentido de que apenas 09 porções de cocaína lhe pertenciam, e a versão dos policiais, no sentido de que 09 porções de cocaína estavam na posse do réu, mas ele foi visto mexendo na sacola onde estava o restante da droga.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Num primeiro momento, tem-se que toda a droga estava embalada da mesma forma, o que indica que a procedência era a mesma.

De outro lado, o réu foi visto pelos policiais mexendo na sacola onde estavam os quites de entorpecente, fato que não ocorreria, se ele não fosse o responsável pela droga, em outras palavras, se o traficante fosse outro, ele não permitiria que o réu mexesse na sacola onde estava sua mercadoria, já que costumam ficar nas proximidades da droga escondida, exatamente para que não se percam. Além disso, os policiais logo localizaram a droga, demonstrando que sabiam onde ela estava escondida.

A prova, portanto, confirma a versão dos policiais militares, que deve prevalecer sobre a negativa de autoria por parte do réu.

Assim, devemos dar crédito ao depoimento uníssono e seguro dos policiais militares que, como funcionários públicos, não estão impedidos de depor. Por outro lado, a palavra dos agentes públicos tem validade como prova, em especial como no caso concreto, quando atrelada ao restante da prova produzida.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg.

Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

Ressalto que os policiais não conheciam o réu e, se quisessem prejudicá-lo, não precisaria utilizar-se de quantidade expressiva de drogas.

Comprovado o envolvimento do réu com toda a droga apreendida, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância. O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11).

No caso dos autos, o réu alegou que os 09 microtubos de cocaína eram para seu próprio consumo. A prova dos autos, contudo, confirma que a droga era destinada ao consumo de terceiras pessoas. Vejamos.

Os policiais estavam em patrulhamento em local conhecido como pela existência de intenso tráfico de drogas e o réu, quando viu a aproximação policial se assustou, comportamento que revela sua conduta ilícita.

A quantidade de droga apreendida (138 microtubos de cocaína) também indica a destinação de consumo alheio, porque os usuários não mantêm essa quantidade consigo, na via pública.

A forma de embalagem da droga (em porções individuais) também indica a atividade mercantil (fotografia de fls. 32).

Ademais, informalmente, o réu confessou aos policiais militares que "fazendo dinheiro" e que havia recebido as drogas de "Atílio".

Assim, o local da abordagem, a quantidade de droga, a forma de embalagem, a confissão informal; tudo revela que a droga tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal -Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câm. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor, não sendo cabível a desclassificação.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa.

Entendo que a quantidade de droga, no caso concreto, não é capaz de alterar a pena-base, porquanto não demonstra dolo acima do normal para a prática delitiva.

A reincidência específica (Certidão de fls. 45/46 – Processo nº 1500159-51.2019.8.26.0599) fará com que a pena-base sofra aumento de um sexto: reclusão de 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

Entendo que não é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão, na medida em que ela foi informal e anterior ao interrogatório policial, quando o réu teve oportunidade de confirmá-la, negou-a, demonstrando ausência de intenção de confirmar a acusação.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 não é cabível, em razão da reincidência específica.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime inicial fechado, uma vez que o delito de tráfico de entorpecentes continua sendo crime equiparado aos hediondos e, além disso, o réu é reincidente específico, demonstrando que a pena anterior não foi capaz de afastá-lo da delinquência.

Pena final: reclusão de 05 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, diária-mínima